

《【문제1】 근로자 甲은 해고를 당한 후 사용자인 乙회사를 상대로 해고무효 확인의 소를 제기하고자 한다. 그런데 乙회사는 명칭만 회사일 뿐 A, B, C 3인이 공동으로 출자해서 설립한 민법상 조합에 불과하다. 다음 물음에 답하시오. (50점) (다만 아래 각 지문은 상호 무관함)

(물음1) 甲은 乙회사를 피고로 해서 해고무효 확인의 소를 제기할 수 있는지 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 민법상 조합인 회사를 상대로 한 해고무효 확인의 소 제기 가능성

I. 문제의 제기

- 사안은 민법상 조합인 乙회사를 상대로 근로자 甲이 해고무효 확인의 소를 제기하고자 하는 상황이다. 쟁점으로 <乙회사가 실질적으로 민법상 조합에 불과한 경우, 민사소송법 제52조의 법인 아닌 사단에 해당하여 독자적인 당사자능력을 가질 수 있는지, 아니면 조합원 전원을 피고로 해야 하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 민법상 조합의 당사자능력 유무, 판례의 태도, 당사자능력이 부정될 경우의 소송 수행 방법인 선정당사자 및 조합대리인 제도 등에 대해 논한다.

II. 민법상 조합의 당사자능력

1. 원칙적 부정

(1) 법리적 근거

- 민법상 조합은 2인 이상이 상호 출자하여 공동사업을 경영할 것을 약정함으로써 성립하는 계약관계에 불과하다. 조합 그 자체는 법인격이 없으며, 조합재산은 조합원 전원의 합유로 귀속된다. 따라서 소송법상으로도 원칙적으로 조합 자체는 당사자능력이 없다.

(2) 판례의 태도

- “대법원”은 민법상 조합은 법인격이 없고 사단성도 결여되어 있으므로 “민사소송법 제52조”가 정하는 법인 아닌 사단에 해당하지 않는다고 본다. 따라서 조합 명의로 소를 제기하거나 조합을 피고로 하여 소를 제기하는 것은 부적법하다는 것이 일관된 입장이다.

2. 법인 아닌 사단과의 구별

(1) 구별 기준

- 어떤 단체가 법인 아닌 사단인지 아니면 민법상 조합인지는 그 단체의 실질에 따라 판단한다. 고유한 명칭을 가지고 사회적 활동을 하며, 의사결정 기관과 집행기관을 갖추고, 구성원의 변경에 관계없이 단체 자체가 존속하는 등 단체성이 강하면 법인 아닌 사단으로 본다.

(2) 사안의 경우

- 문제에서 乙회사는 명칭만 회사일 뿐 3인이 공동으로 출자하여 설립한 민법상 조합에 불과하다고 명시되어 있다. 따라서 특별한 단체적 조직을 갖추지 못한 순수한 조합으로 보아야 하며, “민사소송법 제52조”를 적용하기 어렵다.

III. 조합 소송의 수행 방법

1. 조합원 전원에 의한 소송(합유관계)

(1) 필수적 공동소송

- 조합재산에 관한 소송이나 조합의 채무에 관한 소송은 원칙적으로 조합원 전원이 당사자가 되어야 하는 고유필수적 공동소송에 해당한다. 따라서 甲이 乙회사를 상대로 소를 제기하려면 조합원 A, B, C 전원을 공동피고로 하여 소를 제기해야 한다.

(2) 흠결의 효과

- 조합원 중 일부만을 피고로 하거나 조합 명의로만 소를 제기한 경우, 이는 당사자능력이 없는 자를 상대로 한 것이거나 당사자확정이 잘못된 것으로서 부적법 각하 대상이 된다.

2. 소송 수행의 편의를 위한 제도

(1) 선정당사자[민사소송법 제53조]

- 조합원 전원이 당사자가 되어야 함이 원칙이나, 절차의 간소화를 위해 조합원 중 1인 또는 수인을 선정당사자로 선임하여 소송을 수행하게 할 수 있다. 이 경우 선정되지 않은 나머지 조합원들은 소송에서 탈퇴하게 된다.

(2) 조합대리인에 의한 소송

- 조합의 업무집행조합원이 있는 경우, 그에게 소송대리권을 수여하여 소송을 진행할 수 있으나, 이는 당사자 명의 자체를 조합으로 할 수 있다는 의미는 아니며 여전히 당사자는 조합원 전원이 되어야 한다.

IV. 사안의 적용

1. 乙회사의 당사자능력 부정

- 乙회사는 민법상 조합에 불과하므로 “민사소송법 제52조”의 법인 아닌 사단에 해당하지 않는다. 따라서 乙회사라는 명칭을 피고로 적시하여 소를 제기하는 것은 당사자능력이 없는 자를 피고로 한 것이 되어 부적법하다.

2. 올바른 피고의 지정

- 甲은 해고무효 확인의 소를 제기함에 있어 乙회사의 구성원인 A, B, C 3인 전원을 피고로 지정하여 공동소송의 형태로 제기하여야 한다. 만약 乙회사만을 피고로 제기했다면 법원은 석명권을 행사하여 피고를 조합원 전원으로 보정하도록 명하여야 하며, 이에 응하지 않을 경우 소를 각하해야 한다.

V. 결론

- 민법상 조합은 독자적인 당사자능력을 가지지 못한다는 것이 통설과 “판례”의 입장이다. 따라서 甲은 乙회사를 피고로 하여 해고무효 확인의 소를 제기할 수 없다. 甲은 乙회사의 실질적 운영자인 조합원 A, B, C 전원을 공동피고로 하여 소를 제기하여야 하며, 이것이 소송법상 적법한 소제기 방법이다.